

1500355-15.2021.8.26.0546

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: PAULO ROGERIO MALVEZZI

Comarca: Mogi-Guaçu

Foro: Foro de Mogi Guaçu

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 14/02/2022

... do entorpecente. A esse respeito:

"O crime de tráfico de entorpecentes é configurado ainda que não haja venda de tóxico, mas evidenciada somente a posse do produto destinado a consumo de outrem. Configurando crime de perigo abstrato, o tráfico não exige efetiva oferta da droga a terceiro, pois o bem jurídico tutelado é a saúde pública. É condenável a simples possibilidade ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mogi-Guaçu

Foro de Mogi Guaçu

Vara Criminal

Rua José Colombo, 45, Mogi Guacu - SP - cep 13840-065

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1500355-15.2021.8.26.0546 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500355-15.2021.8.26.0546

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUCAS PORTO FERNANDES

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). PAULO ROGERIO MALVEZZI

Vistos.

Lucas Porto Fernandes foi denunciado e está sendo processado, porque no dia 25 de setembro de 2021, por volta das 16h35min, na Rua Osvaldo Marchiori, 180, Jardim América, neste Município e Comarca de Mogi Guaçu, nas imediações dos estabelecimentos de ensino "CEI Leonor Mendes Barros", "EMEI Gilberto Bueno", "EMEF Professora Anira Franco de Campos", de três praças públicas e de dois campos de futebol e playground, trazia consigo, para fins de tráfico e entrega a terceiros, 69 microtubos contendo cocaína, pesando 47 g (quarenta e sete gramas), substância entorpecente que determina dependência física e psíquica, e o faziam sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. O acusado foi notificado (fls. 225), apresentou defesa prévia (fls. 190/197) e a denúncia foi recebida aos 23 de novembro de 2021 (fls. 219/220). Durante a instrução, foram ouvidas testemunhas e o réu foi interrogado. A representante do Ministério Público pugnou pela procedência da ação penal e condenando nos termos descritos pela denúncia. A defesa requer a improcedência da ação penal, com consequente absolvição do réu, sustentando que não se tem certeza de que a droga lhe pertencia, pois "Eduardo

gigante" jogou a sacola para que o acusado segurasse. Afirma que o acusado desconhecia o conteúdo da sacola. Alternativamente, requer seja afastada a causa de aumento de pena prevista no artigo 40, III, da lei antidrogas e o reconhecimento da confissão espontânea. Invoca ser usuário, nos termos do artigo 28 da lei n. 11.343/06 e padecer de saúde precária, sendo que ainda estava em tratamento em razão de enfermidade grave.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

No mérito, a materialidade delitiva está demonstrada pelo auto de exibição e apreensão (fls. 10); pelo auto de constatação provisória de substância entorpecente (fls. 09), pelo laudo pericial do local (fls. 140/145); pelo laudo de exame químico-toxicológico (fls. 137/139) e por toda a prova oral colhida em juízo.

O guarda municipal Everton Rodrigo dos Santos disse que realizava patrulhamento pelo local dos fatos, área conhecida por ser ponto de tráfico de drogas, e visualizou o acusado em uma bicicleta. Ao perceber a guarnição, ele demonstrou nervosismo e tentou deixar o local, mas foi abordado, apreendendo um invólucro contendo 69 microtubos e dinheiro. O acusado disse que estava com aluguel atrasado. Já havia abordado o acusado diversas vezes, mas nada ilícito apreendeu na ocasião. Não se recorda se havia outras pessoas em bicicletas no local, mas se trata de rua movimentada. Já notou o acusado aparentemente sob efeito de droga.

O guarda municipal Carlos Cezar Borges prestou depoimento no mesmo sentido. Disse que foi o responsável pela busca pessoal, localizando, na cueca dele, invólucro contendo 69 porções de cocaína e dinheiro. Segundo o acusado, enfrentava dificuldade financeira, por isso pegou a droga. Não viu ninguém entregando objeto ao acusado. Não se recorda de haver abordado o acusado anteriormente sob efeito de droga. Não havia outras bicicletas nas imediações. Há bar nas imediações do local da abordagem.

Em solo policial, o acusado Lucas Porto Fernandes disse que é viciado em cocaína e estava no local dos fatos, quando o traficante "gigante" lhe entregou uma sacola e mandou que guardasse, pois já pegaria de volta. Logo após, o interrogado visualizou uma viatura da polícia e percebeu que caíra num golpe, pois, provavelmente, o "gigante" pretendia esconder a droga e usou o interrogado. Disse que não sabia o que continha na sacola, mas desconfiou que era droga e escondeu, assim que viu a viatura (fls. 13).

Em juízo, o acusado disse que passava em via pública quando se deparou com "Gigante", que estava vendendo drogas. Afirma que possuía apenas dez reais em seu bolso. Quando se deparou com "Gigante", cujo nome é Eduardo, ele "empurrou a sacola no peito" do interrogado e pediu que o interrogado segurasse por alguns instantes. Disse que se dirigia ao bar para comprar cigarro quando avistou a viatura e, então, verificou o conteúdo da sacola, percebendo que eram pinos de cocaína. Colocou a sacola em sua cintura e aguardou a abordagem. Disse ao guarda civil que havia recebido a sacola alguns instantes antes, mas não sabia seu conteúdo. Após ingressar no estabelecimento prisional, precisou de atendimento hospitalar em duas ocasiões. Informa que foi removido ao hospital no dia 9 de dezembro, retornando no início do corrente mês.

Com efeito, o depoimento prestado pelos guardas municipais é digno de toda credibilidade, já que devidamente compromissados e inexistentes indícios de interesse dos servidores públicos em prejudicar pessoa inocente. De acordo com a jurisprudência:

PROVA - Depoimento policial - Eficácia - Mera condição de agente público que não torna a testemunha impedida ou suspeita - Precedentes - Recurso improvido.

(Apelação Criminal n. 974.712-3/9-00 - Santos - 14ª Câmara Criminal - Relator: Sérgio Ribas - 01.03.2007 - V.U. - Voto n. 4.191).

PROVA - Depoimento policial - Valor - Credibilidade e responsabilidade equivalentes à palavra dos civis, máxime quando corroboradas pelo conjunto probatório -

Precedentes - Recurso improvido. (Apelação Criminal n. 497.707-3/9-00 - Santos - 5ª Câmara Criminal - Relator: Marcos Zanuzzi - 01.03.2007 - V.U. - Voto n. 13.332).

No caso dos autos, não há dúvida de que a sacola contendo as 69 porções de cocaína foram apreendidas na posse do acusado, pois tal fato foi confirmado pelo próprio

incredulado, que, no entanto, negou tivesse conhecimento do conteúdo daquela sacola, afirmando que o traficante "Gigante" a empurrou em seu peito e deixou o local quando percebeu a aproximação da viatura.

Ocorre que nenhum elemento produzido sob o crivo do contraditório confirmou minimamente a versão do acusado, sendo certo que os guardas civis disseram que não viram ninguém entregando objeto ao acusado.

Ainda, deve consignar que a versão apresentada pelo acusado soa inverossímil e carece de credibilidade para ser acolhida, na medida em que ele afirmou que é conhecido como usuário contumaz de drogas no bairro, de modo que não parece crível que o traficante entregue as porções de cocaína ao acusado.

Mesmo que se diga que o traficante "Gigante" o fez apenas para se livrar da abordagem policial, então ele poderia ter escondido a sacola enquanto não era visto pelos guardas civis municipais, arremessando-a, por exemplo, em terrenos ou casas existentes nas imediações de onde se deu o suposto encontro com o acusado.

Afinal, se a troca de objetos com o acusado não foi vista pelos guardas civis, o proprietário da droga poderia ter escondido as porções naqueles locais anteriormente mencionados, minimizando, ou quiçá evitando, que fosse delatado pelo acusado.

Por tais elementos, além de não comprovada, tenho como inverossímil a versão apresentada pelo acusado, ressaltando que os guardas civis não avistaram nenhuma pessoa se evadindo em bicicleta, como alegado pelo réu.

Assim, não convence a alegação do acusado no sentido de que desconhecia o conteúdo da sacola apreendida em sua posse e que não sabia que no interior dela havia porções de cocaína.

Portanto, tenho que a defesa não logrou comprovar o alegado, encargo que lhe impõe o artigo 156 do Código de Processo Penal.

Desse modo, a quantidade, forma de embalagem e natureza da droga apreendida conduz à inarredável conclusão de que o entorpecente era destinado ao tráfico, revelando-se inacolhível pedido desclassificatório para a figura prevista no artigo 28 da lei antidrogas, conclusão que é reforçada pela ausência de prova de que o acusado teria capacidade financeira para aquisição de tão significativa quantidade de droga.

Bem de ver que o tipo penal descrito no art. 33 da Lei n. 11.343/06 é misto alternativo, de modo que, comprovado que o acusado trazia consigo quantidade expressiva de droga acondicionada de forma fracionada, deve ser dado como incurso naquele preceito legal, sendo dispensável que não tenha sido flagrado na venda do entorpecente. A esse respeito:

"O crime de tráfico de entorpecentes é configurado ainda que não haja venda de tóxico, mas evidenciada somente a posse do produto destinado a consumo de outrem. Configurando crime de perigo abstrato, o tráfico não exige efetiva oferta da droga a terceiro, pois o bem jurídico tutelado é a saúde pública. É condenável a simples possibilidade de distribuição (gratuita ou onerosa) do entorpecente" (RT 776/663).

"Ademais, é sabido que o tráfico de entorpecentes é delito de ação múltipla ou conteúdo variado cuja consumação se contenta com a aquisição, transporte, depósito, guarda ou simples porte da droga, desde que não seja para consumo pessoal. Daí não haver falar em mero auxílio ao uso de drogas, visto que a paciente foi flagrada na posse de maconha e cocaína. (STJ, HC 211.467/DF, Rel. Min. OG FERNANDES, 6ª TURMA, julgado em 16/08/2011, DJe 31/08/2011).

Importante frisar que não há que se duvidar do relato dos guardas municipais na medida em que não há nenhuma prova de animosidade prévia entre eles e o acusado, não se vislumbrando nenhum indício para imputarem falsamente o crime ao acusado. A alegação de que o acusado padece de graves problemas de saúde não altera o panorama de tudo o que foi exposto até o momento e não justifica a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, na medida em que o parágrafo único, do artigo 318, do Código de Processo Penal, exige prova idônea das circunstâncias previstas naquele dispositivo.

Ocorre que os documentos de fls. 111/117 não configuram prova idônea a demonstrar a necessidade de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar.

Passo à dosagem da pena, em conformidade com o disposto nos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal.

Em primeira fase, entendo que as circunstâncias judiciais são favoráveis ao acusado, de modo que fixo a pena privativa de liberdade em 5 anos de reclusão e pagamento de 500 dias-multa.

Em segunda fase, não há atenuantes, mas está presente a agravante da reincidência, que é múltipla, conforme certidão de fls. 253/256 (autos n. 0002187-40. 2015 e n. 0005984-87.2016, desta Vara Criminal da Comarca de Mogi Guaçu).

Assim, majoro sua pena em 1/5, resultando pena privativa de liberdade de 6 anos de reclusão e pagamento de 600 dias-multa.

Não há que se falar em incidência da atenuante da confissão espontânea, pois o acusado afirmou que recebeu a sacola em que estavam acondicionadas as porções de cocaína sem saber de seu conteúdo, tomando conhecimento do que nela havia apenas com a aproximação da viatura policial.

Em terceira fase, incide a causa de aumento de pena prevista no artigo 40, III, da Lei n. 11.343/06, já que o laudo pericial de local revela que nas imediações do local onde os fatos ocorreram estão localizados estabelecimento de ensino, praças públicas, campo de futebol e playground, o que evidentemente facilita a propagação de drogas.

Aliás, a lei não exige que aqueles sejam os locais especialmente visados pelo infrator, bastando a proximidade física.

A esse respeito: A traficância era exercida em local inequivocamente próximo das escolas "Zumira" e "Rubens Leme Asprino" (distava aproximadamente 800 metros da primeira e 490 metros da segunda - vide fls. 74/7), sendo que para a incidência da majorante referente ao artigo 40, inciso III, não exige a lei que o estabelecimento de ensino seja especialmente visado pelo infrator, bastando, tão somente, a proximidade física e o conhecimento dessa proximidade. (TJSP, Apelação n. 0004114-44.2011.8.26.0083, Relator Des. Geraldo Wohlers, julgado aos 26.2.2013, 3ª Câmara de Direito Criminal).

Ainda sobre essa questão, o Col. Supremo Tribunal Federal já teve a oportunidade de se pronunciar no sentido de que "(...) O tráfico de drogas nas imediações de estabelecimentos de ensino é suficiente para incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 40, III, da Lei 11.343/2006, independente de os agentes visarem ou não os frequentadores daquele local (...). Destarte, não procede a alegação da impetrante no sentido de que não há demonstrativo de relação evidente entre a conduta dos pacientes e as atividades desenvolvidas pelos estabelecimentos ensino, uma vez que é irrelevante o fato de haver ou não intenção dos acusados de atingir os frequentadores do estabelecimento. Para incidência da mencionada causa de aumento de pena, basta a proximidade física do local onde o tráfico estava sendo praticado e o estabelecimento de ensino, o que ficou corretamente assentado pelas instâncias ordinárias." (HC 116.929/SP, 1ª Turma, relator Min. Luiz Fux, julgado aos 15.10.2013).

No mesmo sentido, posiciona-se o E. Superior Tribunal de Justiça, que em precedente desta Comarca decidiu que: No entanto, o Superior Tribunal de Justiça possuía entendimento no sentido de ser desnecessária, para a incidência da majorante do artigo 40, III, da lei de drogas, a comprovação de que o comércio de ilícito de substâncias entorpecentes vise atingir os alunos do estabelecimento, bastando, para sua incidência, que a prática da traficância tenha ocorrido nas imediações da escola (RESP n. 1.774.414/SP, rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 22.2.2019).

Por estes motivos, majoro a pena em 1/6, resultando pena privativa de liberdade de 7 anos de reclusão e pagamento de 700 dias multa.

Ainda em terceira fase, inviável a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/06, porque o acusado é reincidente múltiplo. Cada dia-multa será calculado no mínimo legal.

A pena privativa de liberdade deverá ser cumprida em regime inicialmente FECHADO porque o acusado é duplamente reincidente.

Inviável a substituição da privativa de liberdade por restritiva de direitos, em razão do total da pena imposta.

Por estas razões, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal e CONDENO Lucas Porto Fernandes à pena privativa de liberdade de 7 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 700 dias-multa, cada qual no mínimo legal, dando-o como

incurso no art. 33, caput, c.c. art. 40, III, da Lei nº 11.343/06.

O réu respondeu ao processo no cárcere e com a condenação ficam reforçados os motivos que ensejaram a custódia cautelar, razão pela qual lhe nego o direito de recorrer em liberdade, anotando, ainda, que o crime de tráfico de droga atenta contra a ordem pública, fustigada pelo avassalador crescimento dessa prática espúria.

Ademais, trata-se de agente reincidente múltiplo, o que indica que sua liberdade configura risco concreto à ordem pública. Recomende-se na prisão, com expedição de ofício.

Como já consignado, não é o caso de substituir a prisão cautelar por prisão domiciliar, na medida em que não há documento idôneo demonstrando que o agente padece de doença grave que imponha o acolhimento de tal providência (art. 318, parágrafo único do Código de Processo Penal),

Deixo de aplicar o quanto disposto no artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal, pois o acusado não atingiu o lapso temporal para eventual progressão de regime.

Decreto o perdimento do numerário apreendido, pois não comprovada a origem lícita. Custas ex lege, observada eventual gratuidade da justiça.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados.

PRI.

Mogi Guacu, 14 de fevereiro de 2022.

Paulo Rogério Malvezzi
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA